

窃盗罪における不法領得の意思についての次の各【見解】に従って後記の各【事例】における甲の罪責を検討した場合、後記1から5までの各【記述】のうち、正しいものはどれか。なお、後記の各【事例】における甲の行為は、いずれも窃盗罪の客観的要件を全て満たすものとする。

【見 解】

- A. 不法領得の意思として、権利者を排除して所有者として振る舞う意思及び何らかの用途に従って利用・処分する意思が必要である。
- B. 不法領得の意思として、権利者を排除して所有者として振る舞う意思は必要であるが、何らかの用途に従って利用・処分する意思は不要である。
- C. 不法領得の意思として、何らかの用途に従って利用・処分する意思は必要であるが、権利者を排除して所有者として振る舞う意思は不要である。
- D. 不法領得の意思は不要である。

【事 例】

- I. 甲は、勤務先の会社の上司乙を困らせる目的で、乙が机の引き出し内に保管していた同社の銀行届出印をひそかに持ち出し、自宅の天井裏に隠匿した。
- II. 甲は、乙が不在であることを知り、一時的に借用して直ちに戻す意思で、乙方の玄関先に無施錠で駐輪されていた乙の自転車が無断で乗り出し、100メートル先の店まで移動して用事を済ませ、その乗り出しから5分後、同自転車を同玄関先に戻した。
- III. 甲は、X市議会議員選挙に際し、候補者乙の得票数を水増しする目的で、同市選挙管理委員会が保管していた投票用紙50枚を投票所から持ち出し、乙の支持者らに交付して乙に対する投票を依頼した。

【記 述】

- 1. A及びBいずれの見解によっても、事例Iでは窃盗罪が成立する。
- 2. A及びDいずれの見解によっても、事例IIでは窃盗罪が成立する。
- 3. B及びCいずれの見解によっても、事例IIでは窃盗罪が成立する。
- 4. B及びDいずれの見解によっても、事例IIIでは窃盗罪が成立する。
- 5. C及びDいずれの見解によっても、事例Iでは窃盗罪が成立する。

事例Ⅰについて

事例Ⅰの甲は、「勤務先の会社の上司乙を困らせる目的」で銀行届出印を持ち出しており、甲には利用処分意思がないといえる（本事例と類似の事案で不法領得の意思を否定した大判大4.5.21参照）。各【見解】のうち、不法領得の意思として利用処分意思を要求する見解A及びCによれば、甲の不法領得の意思は否定される。これに対して、不法領得の意思として利用処分意思を要求しない見解Bによれば、甲の不法領得の意思は肯定される。そして、不法領得の意思自体を要求しない見解Dによれば、甲の目的は窃盗罪の成否に影響しない。よって、事例Ⅰの甲には、見解A及びCによれば窃盗罪は成立しないが、見解B及びDによれば窃盗罪が成立する。したがって、記述1（見解Aの結論）及び記述5（見解Cの結論）は誤っている。

事例Ⅱについて

事例Ⅱの甲は、「一時的に借用して直ちに返す意思」（一時使用目的）で自転車を取り出しており、権利者排除意思が認められるか問題となる。本事例と類似の事案の判例（無断で自動車を取り回した事案につき不法領得の意思を肯定した最決昭55.10.30、百選Ⅱ32事件）を参考に検討すると、本事例の一時使用目的という甲の認識に加え、自転車という比較的安価な財物であること、使用したのが5分という短時間、かつ100メートル先という短距離であること、乙方の玄関先から取り出して同じ場所に戻したことなどの客観的事情も総合的に評価すると、乙の自転車に対する相当程度の利用可能性を侵害する意思があったとはいえない。よって、甲に権利者排除意思はないといえる。各【見解】のうち、不法領得の意思として権利者排除意思を要求する見解A及びBによれば、甲の不法領得の意思は否定される。これに対して、甲の行為は、窃盗罪の客観的構成要件をすべて満たすものとされているので、不法領得の意思として権利者排除意思を要求しない見解C及びDによると、甲に窃盗罪が成立することになる（下記※参照）。よって、事例Ⅱの甲には、見解A及びBによれば窃盗罪は成立しないが、見解C及びDによれば窃盗罪が成立する。したがって、記述2（見解Aの結論）及び記述3（見解Bの結論）は誤っている。

※見解C及びDに立つ学説は、上記の論理的帰結にもかかわらず、本件のような使用窃盗の場合、占有侵害の軽微性あるいは可罰的違法性の欠如という別の理論構成によって窃盗罪の成立を否定しているが、そのように考えたとしても記述2及び記述3は誤りといえる。

事例Ⅲについて

事例Ⅲの甲は、「得票数を増加させる目的」という経済的用法とはいえない目的で投票用紙を持ち出しており、利用処分意思が認められるかが問題となる。判例（最判昭33.4.17）は、本事例と同様の事案において、不法領得の意思として、権利者排除意思及び利用処分意思いずれも肯定している。同判例は、利用処分意思は「本来の用法に従い利用処分する意思」でもよいと拡張したものと解されている。同判例を踏まえると、見解AからCいずれによっても、甲に不法領得の意思が肯定される。そして、不法領得の意思自体を要求しない見解Dによれば、甲の目的は窃盗罪の成否に影響しない。よって、事例Ⅲの甲には、各【見解】のいずれによっても窃盗罪が成立する。したがって、記述4は正しい。